

1500331-67.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... momento o réu negou a propriedade da sacola e o tráfico de droga. Afirmaram que o local é ponto de tráfico. Na sacola havia aproximadamente 100 porções de droga. Não avistaram o réu praticar ato de venda de drogas. Foi levado para delegacia.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500331-67.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500331-67.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GABRIEL PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual LEONARDO GABRIEL PEREIRA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 85/87) que, no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 07h00min, na Rua Paranaense, s/nº, Conceição, nesta cidade e Comarca de Osasco, LEONARDO GABRIEL PEREIRA, qualificado a fls. 06, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de terceiros, consistentes em 50 (cinquenta) invólucros plásticos, tipo "eppendorf", contendo cocaína, no total de 79,40g (setenta e nove gramas e quarenta centigramas); 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", no total de 40,5g (quarenta gramas e cinquenta centigramas); 11 (onze) unidades de maconha, contendo 13,8g (treze gramas e oitenta centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18, laudos de constatação de fls. 24/27 e 20/22, fotografias a fls. 19/22 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 63/65.

Segundo se apurou, na data do ocorrido, policiais civis, estavam no interior de viatura caracterizada, objetivando o cumprimento de mandados de prisão quando

avistaram o denunciado, o qual demonstrou nervosismo e jogou uma sacola plástica no chão. Diante desta atitude suspeita, os milicianos decidiram abordá-lo.

Em revista pessoal foi localizado com LEONARDO R\$ 50,00 em dinheiro. Na sacola plástica que o denunciado dispensou no chão, foram localizadas as drogas acima descritas.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/03.

Auto de exibição e apreensão às fls. 18.

Fotografia dos entorpecentes apreendidos às fls. 19/22.

Laudo toxicológico às fls. 24/27. Laudo toxicológico definitivo às fls. 63/65.

Em sede de audiência de custódia (fls. 45/48), foi concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado, mediante imposição de medidas cautelares diversas. Alvará de soltura cumprido às fls. 51/52.

Em despacho de fls. 88, foi determinada a notificação do acusado.

Notificado às fls. 92, o acusado apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 96).

A denúncia foi recebida às fls. 99, sendo determinada a citação do réu e designada audiência. Contudo, a audiência não ocorreu, nem foi feita a citação do réu.

Às fls. 112/113, foi então designada audiência de instrução, debates e julgamento presencial para o dia 21.11.2022, às 13h30.

Folha de antecedentes e demais certidões em nome do acusado às fls. 118/124. Em debates foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em debates a Acusação pediu a condenação nos termos da inicial.

Em debates a defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas. Em caso de condenação, diante da primariedade, pena base e regime diverso do fechado. Apontou que a quantidade de droga apreendida, sem os plástico, é menor do que aquela apontada na denúncia.

É relatório.

Fundamento e decido

A - Preliminarmente, anoto que não se verifica ilegalidade na conduta dos policiais a ponto de tornar a prova ilícita. A abordagem policial não foi tão somente baseada em "tiroteio" dos agentes públicos ou somente em "nervosismo", o que denotaria o mais puro subjetivismo, mas sim em comportamento efetivo, vale dizer, porque o réu, ao caminhar pela via pública, avistou a viatura caracterizada, e, neste momento, deu uma parada. Dispensou algo no chão e continuou a caminhar. Assim, cumprido o standard do art. 244 do CPP para atuação policial.

B - Do mérito

B.1 - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 19/22) e fotografia (fls. 63/65).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"), eis que o réu, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, ainda que não expressiva, trazia entorpecentes destinado a terceiras pessoas.

O réu, ouvido em juízo, no exercício da autodefesa, negou os fatos. Afirmou que estava pela manhã em um bar. Caminhou pelo local, o qual, ao final da rua, possui um córrego, para ir para casa de sua namorada. Viu que havia uma viatura pelas suas costas e outra do outro lado do córrego. Foi abordado. Os policiais disseram que tudo que seria encontrado no local seria a ele atribuído. Confirmou que trazia 50 reais no bolso e que, enquanto permaneceu com um policial, o outro entrou no córrego e voltou com uma sacola nas mãos. O policial ao entrar no córrego não levada nada nas mãos. Nega a propriedade da sacola.

A versão do réu deve ser afastada. As provas produzidas em juízo pelo Ministério Público, corroboradas pelos elementos materiais (laudo e fotografias), permitem a superação da presunção constitucional para além de qualquer dúvida razoável e permite a imposição de pena.

Os policiais em resumo e em essência, de modo coerente, ressaltaram que estavam no local para cumprimento de mandado de prisão. No período da manhã entraram na rua com uma viatura caracterizada. Avistaram uma pessoa ("rapaz") caminhando na direção da viatura a pé. Ao ver a viatura a pessoa parou. Tinha um objeto nas mãos e jogou-o de lado. Na abordagem pela testemunha José Muniz, foi localizada a quantia de 50 reais. Relatam, ainda, que a testemunha Sérgio localizou a sacola que estava a uns 15 metros. Ambos confirmam que no momento o réu negou a propriedade da sacola e o tráfico de droga. Afirmaram que o local é ponto de tráfico. Na sacola havia aproximadamente 100 porções de droga. Não avistaram o réu praticar ato de venda de drogas. Foi levado para delegacia.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão

consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais.

Nesse sentido: (...) 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. (...) (STJ – 5ª Turma - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.936.393 - RJ – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – j. 25.10.2022).

Com efeito, os policiais, em resumo, e essencialmente, afirmaram que, em cumprimento de mandado de prisão de determinada pessoa, avistaram o réu que caminhava pela via pública. Este ao ver a viatura dispensou uma sacola. Enquanto um policial permaneceu com o réu o outro localizou referida sacola com o entorpecente.

Portanto, a premissa fática do Ministério Público, qual seja, que no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 07h00min, na Rua Paranaense, s/nº, Conceição, nesta cidade e Comarca de Osasco, LEONARDO GABRIEL PEREIRA, qualificado a fls. 06, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de terceiros, consistentes em 50 (cinquenta) invólucros plásticos, tipo “eppendorf”, contendo cocaína, no total de 79,40g (setenta e nove gramas e quarenta centigramas); 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de “crack”, no total de 40,5g (quarenta gramas e cinquenta centigramas); 11 (onze) unidades de maconha, contendo 13,8g (treze gramas e oitenta centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18, laudos de constatação de fls. 24/27 e 20/22, fotografias a fls. 19/22 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 63/65 está devidamente comprovada nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de trazer consigo entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e que as drogas seriam para consumo de terceiros, tendo em vista a forma como acondicionadas, a quantidade e as condições nas quais se desenvolveu a ação (o réu ao ver os policiais dispensou uma sacola, após titubear por um momento). Não há dúvidas, portanto, que a droga estava com o réu – em uma sacola – e se destinava ao comércio espúrio. Em que pese haver pequenas divergências nos depoimentos e o fato da réu não ter interagido com outras pessoas para venda de drogas, estes pontos não são capazes de infirmar a prova produzida e afastar a responsabilidade penal.

B.2 – Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário ao tempo do fato, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal e ser portador de bons antecedentes (sem condenação não apta a gerar reincidência) – 43/44. Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, não há qualquer elemento que demonstre que o réu se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação do réu à atividade ligada ao tráfico, até porque a quantidade de drogas, como anotado pela defesa, não é expressiva, ainda mais se descontado o peso dos plásticos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer à organização criminosa. Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta, qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: “§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela. Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

No caso dos autos, não há qualquer mínimo elemento que demonstre de forma pressuposta envolvimento com organização criminosa.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a

quantidade de drogas é não significativa e, ainda, o réu, ao tempo do fato, era primário, sem antecedentes (fls. 19/22).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias multa.

O ré preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mais multa.

A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

Somando-se as multas chega-se ao total de 177 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas da ré.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:
CONDENO LEONARDO GABRIEL PEREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 177 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração aos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

E - Demais deliberações

Pela natureza da sanção o réu poderá recorrer em liberdade e até porque não se encontra preso por este feito.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Determino a destruição dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e

Realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no

art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 30 de novembro de 2022.